

114年公務人員特種考試司法官考試第二試
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試
法律專業科目評分要點與閱卷委員的話

科目：憲法與行政法

第一題

【總題說明】

本題的第(一)子題旨在測試考生有關商業性言論(藥物廣告)事前審查合憲性的相關解釋及理論分析。評分重點在於考生是否能援引釋字第414號與釋字第744號兩號大法官解釋，並分析兩者之異同。在違憲理由部分，能否掌握以下核心爭議：「商業性言論」之「事前審查」(言論自由)、審查標準/密度之選擇(嚴格審查)，並藉由目的及手段關連之分析，如比例原則之具體操作，從甲公司(藥商)之立場分析說明系爭條文違憲之理由。至於本題的第(二)子題則著重測試考生有關憲法平等保障的理解及操作。主要作答依據應參考憲法法庭112年憲判字第17號判決及平等原則，分析說明以藥商身分為區別標準，據而規範得否刊播藥物廣告(言論自由)之差別待遇是否合憲之問題。考生若能引述釋字794號解釋意旨，則可另外酌予以加分。而本題的第(三)子題，命題意旨在於測試考生是否了解「一行為不二罰」原則中，所謂「一行為」之內涵，以及實務上最高行政法院對此之重要見解，特別是最高行政法院105年10月份第1次庭長法官聯席會議決議。若考生能深入討論「單純通知」和「實際裁處」之異同，並用以認定一行為之概念並決定本案違規行為之次數，且有合理論述者，可給予平均以上分數。如可進一步討論認定標準需要有法令明確規範，以免行政機關恣意，則進一步酌予加分。

【評分要點】

第(一)子題—關於商業性言論(藥物廣告)事前審查之合憲性問題

第(一)子題主要涉及司法院大法官就有關「商業性言論(藥物廣告)事前審查合憲性」的相關解釋意旨及比例原則。以下從甲藥商之立場出發，具體分析藥事法第66條第1項可能違憲之理由：

1、相關大法官解釋之見解：

(1)釋字第414號解釋認為「藥物廣告之事前審查合憲」，本號解釋至今並未被

正式變更。其解釋文要旨謂：「藥物廣告係為獲得財產而從事之經濟活動，涉及財產權之保障，並具商業上意見表達之性質，惟因與國民健康有重大關係，基於公共利益之維護，應受較嚴格之規範。藥事法第 66 條第 1 項規定：藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請省（市）衛生主管機關核准，旨在確保藥物廣告之真實，維護國民健康，為增進公共利益所必要，與憲法第 11 條及第 15 條尚屬相符。」其理由書指出：「言論自由，在於保障意見之自由流通，使人民有取得充分資訊及自我實現之機會，包括政治、學術、宗教及商業言論等，並依其性質而有不同之保護範疇及限制之準則。其中非關公意形成、真理發現或信仰表達之商業言論，尚不能與其他言論自由之保障等量齊觀。」基本上亦與我國學理引介美國言論自由之雙階理論，隱然相合。

- (2) 但釋字第 744 號解釋則對商業性言論事前審查持不同見解，並認為「化妝品廣告之事前審查違憲」，應適用嚴格審查標準。其理由書指出：「化粧品廣告係利用傳播方法，宣傳化粧品效能，以達招徠銷售為目的，具商業上意見表達之性質。商業言論所提供之訊息，內容非虛偽不實或不致產生誤導作用，以合法交易為目的而有助於消費大眾作出經濟上之合理抉擇者，應受憲法第 11 條言論自由之保障（釋字第 577 號、第 623 號解釋參照）。」並認為「化粧品廣告之事前審查乃對言論自由之重大干預，原則上應為違憲。系爭規定之立法資料須足以支持對化粧品廣告之事前審查，係為防免人民生命、身體、健康遭受直接、立即及難以回復危害之特別重要之公共利益目的，其與目的之達成間具直接及絕對必要關聯，且賦予人民獲立即司法救濟之機會，始符合憲法比例原則及保障言論自由之意旨。」亦即，就化粧品衛生管理條例針對化粧品廣告所為之事前審查，限制化粧品廠商之言論自由，已逾越必要程度，不符憲法第 23 條之比例原則。
- (3) 上述釋字第 414 號與釋字第 744 號兩號解釋雖均牽涉法律賦予主管機關就商業性言論進行事前審查之合憲性爭議，並同以比例原則作為違憲審查之標準，惟後者採用嚴格之審查標準。釋字第 744 號並未明文推翻釋字第 414 號，也未廣泛地明言將嚴格審查標準適用於其他類型廣告之事前審查，或是否及於所有言論的事前審查，然其已將商業性言論的事前審查之案件採用嚴格審查標準。準此，本子題的提問係「從甲公司之立場」來作答。因此，從甲公司之立場而言，其目的乃意欲主張藥事法第 66 條第 1 項違憲，其理

由應參採釋字第 744 號解釋之嚴格審查標準，據而主張對系爭法條違憲，始對甲藥商較為有利。

2、甲公司得主張藥事法第 66 條第 1 項違憲之理由

- (1) 憲法上權利之根據：言論自由。參酌釋字第 509 號理由書意旨：「憲法第 11 條規定，人民之言論自由應予保障，鑑於言論自由有實現自我、溝通意見、追求真理、滿足人民知的權利，形成公意，促進各種合理的政治及社會活動之功能，乃維持民主多元社會正常發展不可或缺之機制，國家應給予最大限度之保障。」釋字 577 號及釋字 744 號亦肯認商業性言論，若其內容非虛偽不實或不致產生誤導作用者，其所具有資訊提供、意見形成進而自我實現之功能，與其他事務領域之言論並無二致，應屬憲法第 11 條言論自由保障之範圍。
- (2) 審查標準與審查密度：藥物廣告及化粧品廣告固然同屬商業性言論，於本題亦應可同採比例原則作為司法違憲審查之標準。然對於事前審查機制，甲公司得主張司法審查密度應改依釋字第 744 號解釋所採之嚴格審查密度，而不再繼續適用釋字第 414 解釋之寬鬆審查密度，理由申述如下。
- (3) 從目的以觀：系爭規定應追求特別重要的公益目的，亦即：僅限於為防止或避免對人民生命、身體、健康遭受直接、立即及難以回復之危害，始足以構成特別重要的公益目的。藥物廣告只是誘引消費者購買，尚不足以直接、立即發生上述危害，故系爭藥事法第 66 條第 1 項規定之目的已經違憲。
- (4) 就手段而論：除了事前審查外，主管機關尚可透過事後追懲手段，來減少不實廣告之可能危害，故事前審查並非不可或缺之必要手段。且系爭規定對於事前審查機制之規範，欠缺足夠的程序保障，使人民得以在預定刊播廣告之前，可透過法院尋求有效的救濟。故系爭規定之手段亦屬違憲。

第(二)子題—以平等原則檢視藥事法規定「非藥商不得為藥物廣告」之合憲性問題

第(二)子題主要涉及憲法法庭 112 年憲判字第 17 號判決及平等原則，以藥商身分為區別標準，而得否刊播藥物廣告（言論自由）之差別待遇是否合憲之問題。

1、相關大法官解釋之見解：

- (1) 有關平等原則之意義，依釋字第 485 號解釋文：「憲法第 7 條平等原則並非指絕對、機械之形式上平等，而係保障人民在法律上地位之實質平等，立法

機關基於憲法之價值體系及立法目的，自得斟酌規範事物性質之差異而為合理之區別對待。」

(2) 至於差別待遇是否合憲的問題，更涉及對該差別待遇所應採之司法審查標準。我國大法官過往實務見解認為，法規範所為差別待遇，是否符合平等保障之要求，應視該差別待遇之目的是否合憲，及其所採取之分類與規範目的之達成間，是否存有一定程度之關聯性而定（司法院釋字第 682 號、第 722 號、第 745 號、第 750 號、第 791 號、第 802 號解釋及 111 憲判字 4 號判決參照）。法規範所採取之分類如未涉及可疑分類，且其差別待遇並不涉及攸關個人人格發展及人性尊嚴之重要基本權利，本院自得採寬鬆標準予以審查（司法院釋字第 768、794、802 號參照）。然而，依釋字 794 號解釋意旨：「法規範如以種族、性別、性傾向等為分類，因此等分類往往涉及難以改變之個人特徵，或屬受有各種事實上或法律上之排斥或歧視者，或為社會上孤立隔絕之少數且為政治上之弱勢，本院對於此等分類，應加強審查，而適用嚴格或較為嚴格之審查標準，以判斷其合憲性」。

(3) 就藥事法第 65 條規定是否違反憲法保障之平等原則，首應判斷應採何種標準進行審查。固然，釋字第 768 號有謂：「以職業別為基礎所為之分類，並未涉及可疑分類，應採寬鬆審查。」以是否為藥商為分類標準並不涉及可疑分類，然參酌 112 年憲判字第 17 號判決，對醫師為醫療廣告之言論自由管制，認為醫療法規定「非醫療機構，不得為醫療廣告」，其中關於禁止醫師為醫療廣告之部分，與憲法第 11 條保障言論自由之意旨有違。其理由書更指出：「醫療廣告除係宣傳醫療業務，以招徠患者外，亦含有彰顯醫師自我表現，向大眾傳遞醫療訊息之性質，對於民眾就醫之選擇，亦有提供參考資訊之功能。在以保障言論自由為重要內涵之我國憲法規定下，即使為從事醫療專業之醫師，就其專業有關之言論自由，亦不能完全排除。」足見過往憲法實務認為醫師關於醫療廣告受有言論自由之保障。

2、乙主張藥事法第 65 條規定違反平等原則而違憲，是否有理由，分析如下：

(1) 權利基礎：平等、言論自由。藥事法所稱之藥商，依同法第 14 條規定係指：「藥品或醫療器材販賣業者」與「藥品或醫療器材製造業者」。因此，乙之所以主張第 65 條規定違反平等原則，應係乙雖為藥師，但並依該法仍不具備藥商之資格，合先敘明。基此，就平等原則而言，以藥商身為區別標準，限制非藥商不得為藥物廣告，構成得否刊播藥物廣告（言論自由）之差

別待遇。

- (2)有關審查標準與審查密度：至於此一差別待遇是否違憲，所採審查標準得採釋字 768 號之合理標準審查或是參酌 112 年憲判字第 17 號判決主張藥師之言論自由為重要基本權而採中度標準。蓋是否具備藥商資格並未涉及難以改變之個人特徵，或屬受有各種事實上或法律上之排斥或歧視者，或為社會上孤立隔絕之少數且為政治上之弱勢，因此並非可疑分類。但考生亦能參酌 112 年憲判字第 17 號判決，雖然本題的乙係藥師而非醫師，但藥師刊播藥物廣告之行為與醫師從事醫療廣告有其相似性，均涉及行使憲法第 11 條保障的言論自由，並主張藥師之商業性言論自由為攸關個人人格發展及人性尊嚴之重要基本權利，乃攸關藥師之重要基本權，因而得主張提高審查為中度審查標準。
- (3)準此，若採取合理審查標準，乙主張藥事法第 65 條規定違反憲法保障之平等原則，應無理由。因該條之立法目的旨在確保藥物廣告內容之盡可能真實、正確，以維護國民健康及或藥物交易市場之秩序，故僅允許藥商得為藥物廣告並納入管制，以避免非藥商可能藉由誇大不實、引人錯誤之廣告，促銷藥物而有助長藥物濫用之風險，其目的洵屬正當，差別待遇之手段亦具合理關聯。若採取中度審查標準，以維護國民健康及或藥物交易市場之秩序足以構成重要公共利益，以限制個別藥師進行藥物廣告促銷藥物，以利政府對於藥品之管制，其限制個別藥師進行藥物廣告之商業性言論自由為手段，應也可通過實質關聯性之審查。

第(三)子題—行政罰有關「一行為」之認定

第(三)子題主要涉及行政罰有關「一行為」之認定標準、題文中「書面告知」之意義，以及法令規範是否符合明確性原則之爭議。

1、一行為之意義

行政罰法第 24 條第 1 項之所謂「一行為」，其概念包含「自然一行為」與「法律上一行為」。所謂「自然一行為」，係指行為人只有一個身體之動作，或雖有多數在行政罰法上具有重要性之行為態樣，然依一般人以自然之方式客觀觀察，可認為其整個行為過程係單一之整合行為者。所謂「法律上一行為」，係指結合多數自然意義之動作而成之單一行為。某些行為雖不符合自然一行為之要件，惟基於立法政策之考量，仍將其評價為一行為。就法律層面之意義

而言，此種行為只構成單一之違法狀態，故只能核予一次處罰。法律上一行為依其型態又可分為：「多次實現構成要件之行為」、「繼續違法行為」等。

2、大法官解釋與司法實務對違規行為之認定標準

釋字第 604 號解釋意旨認為：「主管機關得藉舉發違規事實之次數，作為認定違規行為之次數，從而對此多次違規行為得予以多次處罰，並不生一行為二罰之問題」。準此，主管機關得以「舉發次數」來認定違規行為之次數；又連續舉發之條件及前後舉發之間隔及期間，應以法律或命令為明確之規範。

其次，最高行政法院 105 年 10 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議，藥事法第 65 條課以非藥商不得為藥物廣告之行政法上不作為義務。同法第 24 條規定：「本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。」而「廣告」乃集合性概念，一次或多次利用傳播方法為宣傳，以達招徠銷售為目的之行為，均屬之。非藥商多次重複地利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為，如係出於違反藥事法第 65 條之不作為義務之單一意思，該多次違規行為在法律上應評價為一行為，於主管機關裁處後，始切斷違規行為之單一性。

3、本案之認定

- (1) 如依最高行政法院前述決議，乙刊播廣告之行為，核其時間密集、行為緊接，如無其他相反事證，應可認為是出於違反藥事法第 65 條行政法上義務之單一意思，該當於一個違反藥事法第 65 條行政法上義務之行為，為一行為而非數行為。但本件決議以主管機關「裁處」，為區別法律上行為之認定標準，與釋字第 604 號解釋意旨相同。換言之，書面通知（警告）與裁處有相同之阻斷一行為的效果，故 4 月 12 日至 5 月 20 日間之刊播行為不只構成一個違規行為。主管機關可得藉由 4 月 12 日至 20 日、4 月 21 日至 30 日的「書面告知」，以及 5 月 1 日至 20 日之刊播廣告行為，藉由 5 月 20 日之裁處將乙之違法行為予以切割，進而處罰 3 次罰鍰，並就 5 月 21 日至 25 日之廣告刊播行為，按日連續處罰 5 次，共計裁處 8 次罰鍰，應可認為有理由。
- (2) 惟另有見解認為：主管機關在 4 月 20 日及 4 月 30 日之兩次書面告知，只是通知（警告），而非裁處，不生區別法律上違規行為之效果。故主管機關在 5 月 20 日一日內，同時對乙作成 3 次罰鍰處分，並不符合此一認定標

準。故乙在 4 月 12 日至 5 月 20 日間之刊播行為，應只構成一個違規行為，主管機關之 8 次裁罰，應無理由。惟法院目前就此尚無穩定見解。

- (3) 另外，釋字 604 號解釋文亦強調：「立法者固得以法律規定行政機關執法人員得以連續舉發及隨同多次處罰之遏阻作用以達成行政管制之目的，但仍須符合憲法第二十三條之比例原則及法律授權明確性原則。」亦即「將自然單一行為『切割』成數個法律上單一行為，仍不能恣意，凡切割超出達成管制目的所需之限度，將自然意義之一行為切割成數行為，並分別評價及處罰，仍得以違反憲法上『一行為不二罰原則』加以非難。」準此，本題藥事法相關裁罰規定對於「單純書面通知（警告）」之連續舉發的條件及間隔時間和「實際裁處」之異同等，不僅欠缺明確規範，主管機關於 5 月 21 日至 25 日之連續按日 5 次裁處，依題目所附條文，因無得「連續處罰」或得「按日連續處罰」之明文規定，亦可能構成超出管制目的而違反比例原則。因此，藥事法相關裁罰規定應可認為已違反明確性原則，主管機關的 8 次裁罰亦有流於恣意之嫌甚或違反比例原則，故法院應就前述疑義進行審查，認定裁罰並非完全合法有理由。

【閱卷委員的話】

多數考生的作答能呈現出對於基本概念的掌握，比較大的落差呈現在是否能從案例事實精確掌握爭點，並提出完整、有邏輯而一致的推論。

第(一)子題

本題案例涉及藥事法對於藥物廣告的事前核准，關鍵在於考生能否清楚掌握到言論自由限制之審查標準。考生應先分析系爭規範限制的言論類型與限制方式，進而清楚說明如何在言論自由理論與過去解釋的基礎上選擇適當的審查標準。之後，考生應清楚指出其選擇審查標準的內涵，並涵攝於本題案例，深入分析系爭規範是否能通過審查。本案藥事法相關規範也可能限制當事人的工作權或營業自由，考生若有顧及論述，也能顯示其分析的全面性。

多半考生能掌握言論自由的基礎理論，可以清楚呈現雙階、雙軌理論與關鍵的憲法解釋，因此得分的關鍵在於 1. 是否能完整、妥善分析案例事實並論述本案審查標準的決定，以及 2. 將所選定之審查標準涵攝於本題，分析系爭規範之合憲性。此次考試有下列幾項常見的問題：

1. 審查標準決定的論證基礎不足或不一致。部分考生注意到藥品廣告可能是商

業性言論的面向，卻忽略本題規範涉及事前審查；或者強調事前審查卻隻字未提商業性言論，都顯說理不足。許多考生在探討審查標準並選擇後，錯用了審查標準的內涵，或未能清楚展現審查標準在違憲審查的分析。例如以系爭規範的事前審查，而援引釋字第 744 號，有考生選擇中度審查標準卻未論述何以採取與解釋不同的立場；有考生選擇嚴格審查標準，實際上卻是以目的重要及實質關聯等中度審查標準的內涵分析；亦有考生從頭到尾都以比例原則分析，都可惜地未能充分回應本題的核心爭點。

2. 不夠深入的涵攝論證。由於多半考生都能大致掌握言論自由及其審查標準，涵攝的完整與深度是分數高低的關鍵之一。不乏考生討論完審查標準後完全沒有涵攝或泛泛做出結論，例如指出藥事法保護健康即為特別重大公共利益、事前審查即非為必要關聯手段。如果能更深入討論系爭規範具體之目的，探討有哪些其他可能手段同樣能有效達到規範目的，則能更完整說理。
3. 未能呈現重點的制式答題。部分考生答題制式地從程序、形式審查到實質審查逐一盤點，而在爭點與非爭點的議題上花費相同的篇幅。雖然並非錯誤，卻顯得考生未能掌握重點。例如憲法訴訟法的程序要件固然有相關性，但並非本題案例凸顯的爭議，建議扼要說明即可。類似的，不少考生花費相當篇幅檢討藥事法系爭規範的法律明確性，卻未能凸顯系爭規範的爭議性。部分考生花費大量篇幅探討非爭點議題，以至於壓縮實體討論的深度與篇幅，相當可惜。

第(二)子題

本子題的提問在於系爭藥事法第 65 條是否違反平等權，意在確認考生對於平等權內涵以及審查標準的熟稔程度。因此考生應就系爭規範如何形成差別待遇、分類如何影響審查標準、審查標準適用於本案的分析逐一討論。整體而言，答題反映多數考生能掌握平等權的基礎理論與實務進展，因此論證的精確與完整成為分數高低的關鍵。此次答題常見的問題包括：

1. 抽象違憲審查與個案審查的混淆。少數同學將答題重點放在「罰鍰處分」的合法性，卻不是題目所問的藥事法第 65 條合憲性；亦有考生將案例事實與規範合憲性二個層次交雜討論。二者都有混淆抽象違憲審查與個案合法性的疑慮。子題以「平等權」為提問，考生可以略過本案聲請如何符合憲法訴訟法要件、法律明確性、工作權限制的合憲性等問題，或至少應避免過度壓縮平等權相關的論述。

2. 關鍵之一是本題系爭規範涉及何種差別待遇與分類基礎。考生應注意到憲法法庭已經主張涉及所謂「嫌疑類型」的差別待遇應提高審查標準，亦即是否涉及釋字 748、794 提到的「孤立隔絕之少數且為政治上之弱勢」應適用較嚴格審查標準。無論考生決定何種審查標準，都應該提供具體而有說服力的理由。考生應先指出系爭規範的差別待遇及分類基礎，再以憲法解釋論述本案應適用之審查標準。藥事法第 65 條「非藥商不得為藥物廣告」之差別待遇為是否得為藥物廣告，而分類基礎則是藥商與非藥商。許多考生將系爭規範的分類標準界定為藥商與藥師或藥商與一般人，可能不夠精確。
3. 審查標準的決定通常沒有正確答案，因此需要考生說明可能的考量並提出決定的理由。在本案可能涉及嫌疑分類、限制的權利與限制程度，以及司法是否因為本案涉及藥事專業而應尊重政治部門決定等等面向。考生應提出充分的論述，說明其決定審查標準之理由。
4. 同樣的，選擇審查標準後，考生應將審查標準適用於本案規範，以分析系爭規範是否違反憲法平等權之保障。考題提供藥事法關於「藥商」及「藥局」定義與相關規範，期待考生能從相關規範理解藥商與非藥商之區分，並依此檢視背後之目的與手段是否符合憲法平等權之要求。可惜真正能深入分析藥商與非藥商區別的考生相對有限，多數考生泛以藥師亦有專業即做成系爭規範違反平等權之結論，略顯速斷。

第(三)子題

與前兩子題不同，本題是針對行政訴訟程序中具體的「罰鍰處分」合法性爭議。由於實務界對相關問題做出幾次重要的決議或判決，考生除了掌握問題的爭議層次之外，應該檢視實務立場與歧見，進而提出主張並涵攝於本案。本題涉及多個行為及裁罰，爭點也較為複雜，考驗考生能否在梳理問題層次後，以清楚架構逐步推導結論，並注意論述邏輯前後一致。

考生應能先指出本案的爭點在於一事不二罰的爭議，並能分析本題具體的爭點包括連續刊播廣告的行為數判斷以及連續裁罰的性質與合法性。

由於學界與實務界對相關議題尚未有穩定共識，本題案例事實亦容有多種解釋可能，考生應能精確掌握案例事實以釐清問題層次與相關論理。

考生應注意到本題涉及多次裁罰，後面 5 次連續處罰與 5 月 20 日的三個裁罰的性質未必相同，宜分開討論其合法性。部分考生未注意到案例事實的差異而以同一方式評價其合法性，稍嫌速斷。

前三次裁罰主要的問題在於廣告行為的行為數認定，包括連續廣告行為是否應該評價為法律上同一行為，以及主管機關兩次書面通知是否屬於可以切割行為數的法律行為。即使最高行政法院已經做成決議將連續廣告論為集合行為，考生仍應探討 5 月 20 日之前的廣告行為，橫跨數週時間並有二次書面通知，是否應有不同判斷。例如書面通知與實務主張「裁罰」性質不同，是否發生相同切割行為數的效果？

連續處罰的部分，除了同樣涉及「裁罰」是否切割行為數的爭議之外，尚可能涉及連續裁罰性質上是否為怠金、有無送達以及是否有無法律依據、裁量濫用、違反比例原則等爭議。本題案例中，主管機關連續五日裁罰一百萬元，而藥事法第 91 條沒有連續處罰的規定，也期待考生分析後提出主張。換言之，連續處罰即使因為裁罰切割等原因不違反一事不二罰原則，也可能違反其他法律。

第二題

【總題說明】

本題涉及在由憲法及憲法增修條文所形構之中央與地方權限劃分之框架秩序下，地方自治團體就自治事項行使立法權限、中央監督機關對於該等自治立法權限行使之監督，以及行政法院對自治條例之合法性，甚至合憲性之審查權限等問題。主要聚焦於地方自治團體所制定之自治條例在整體規範位階秩序中之定位、行政法院於裁判時，是否應受自治條例之拘束、自治條例是否，以及如何於何等範圍內得作為限制地方居民權利之法規範依據，而與法律保留原則無違，以及於現行法制下，地方自治團體不服其自治條例遭中央監督機關函告無效時之法律救濟途徑等爭點。

【評分要點】

第(一)子題

本子題涉及行政法院是否享有審查地方自治團體所制定之自治條例，並進而於個案中拒絕適用之權限，以及其得否依憲法訴訟法向憲法法庭聲請法規範憲法審查之問題。

1、依憲法第 80 條規定，法官應依據法律獨立審判；該條規定所稱之法律，係指經立法院通過，總統公布之形式意義法律，或學理所稱之國會法。另依司法

院釋字第 371 號、第 572 號以及第 590 號等解釋之意旨可知，對於該等形式意義之法律，各級法院法官於審理案件時，如認為有牴觸憲法之疑義者，僅能依憲法訴訟法之規定向憲法法庭聲請法規範憲法審查，而無自行認定該等形式意義之法律為違憲而逕行拒絕適用之權限；學理對此亦有稱為法官應依實質正當法律審判之要求。此屬應考人須掌握，並進而作為答題依據之釋憲實務見解。

- 2、至於法規命令與行政規則等行政命令，依司法院釋字第 137 號、第 216 號以及第 374 號等解釋所揭示之穩定見解，其對於獨立審判之法官並無法律上之拘束力；換言之，法官於審理案件時，對於所涉及之法規命令與行政規則等行政命令，得對之表示適當之不同見解，並不受其拘束。學理及法院裁判實務見解因而認為，對於法規命令與行政規則等行政命令，法官對其乃享有合法性與合憲性審查之權限，得以其違法或牴觸憲法為由，於審理案件時予以拒絕適用。此同屬應考人得掌握之基本觀念。
- 3、依地方制度法第 30 條第 1 項關於自治條例與基於法律授權之法規，即中央之法規命令牴觸者為無效之規定可知，地方自治團體所制定之自治條例，在整體規範位階秩序中，地位係居於中央法規命令之下。從而，依前所述，行政法院於審理案件時，既然可對其經審查而認為違法或違憲之法規命令等行政命令予以拒絕適用，則位階地位低於中央法規命令之自治條例，行政法院當然同樣對之具有合法性與合憲性之審查權。換言之，行政法院於審理案件時，如認為自治條例之規定違憲，雖不可直接宣告其無效，但仍可予以拒絕適用。由於學理對此或有不同見解，例如有認為，既然自治條例係由具有民主正當性之地方立法機關所制定，則似不應認為其位階地位較低，甚或否定其具有法律之性質。因此，應考人如能妥適地為論理說明，亦會獲得相應之分數。
- 4、基此，行政法院如認為系爭規定違反憲法有關中央與地方權限劃分規定而違憲，則其於審理案件時，即得依此等認定違憲之見解，而拒絕適用系爭規定；丁就此部分之主張，並無理由。
- 5、再者，依憲法訴訟法第 55 條規定，各法院就其審理之案件，對裁判上所應適用之法律位階法規範，依其合理確信，認有牴觸憲法，且於該案件之裁判結果有直接影響者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。由此可知，各法院聲

請憲法法庭為法規範憲法審查之標的，係其裁判上所應適用之法律位階法規範。

- 6、如前所述，地方自治團體所制定之自治條例，其於整體規範位階秩序中係低於中央法規命令；換言之，其並非憲法訴訟法該條規定所稱之法律位階法規範。基此，行政法院於審理案件時，即無法依憲法訴訟法該條規定聲請憲法法庭為法規範憲法審查。故丁就此部分之主張，亦無理由。應考人於此除須援引憲法訴訟法第 55 條規定為答題依據外，並應解釋該條規定所稱之法律位階法規範之概念內涵，以及探究系爭規定是否亦為法律位階法規範。

第(二)子題

本子題涉及在法律保留原則之要求下，地方自治條例得否，或於何等情況下得作為限制人民基本權利之法規範依據之問題。

- 1、依司法院釋字第 467 號解釋及憲法法庭 111 年憲判字第 6 號判決之意旨，基於憲法對於地方自治之制度性保障，地方自治團體就其自治事項，乃有制定規章並執行之自治權限。亦即除憲法明文劃歸中央專屬立法權事項外，各縣就憲法第 110 條所定各事項，本於地方自治因地制宜之精神，就其「有一縣之性質者」，應有其自治立法及執行權；直轄市就「有一直轄市之性質者」，亦同。
- 2、又，依司法院釋字第 443 號解釋意旨，於涉及限制人民基本權利時所依據之法規範，因規範對象、內容或法益本身及其所受限制之輕重等因素所生規範密度之差異，或應以立法院通過，總統公布之形式意義法律為依據，或亦得以經該等形式意義法律授權所訂定之法規命令為依據。另依司法院釋字第 806 號解釋，地方自治事項，凡涉及對居民自由權利之限制者，依法治國原則相同法理，亦有法律保留原則之適用；亦即應以經地方立法機關通過，並由各該行政機關公布之自治條例（地方制度法第 28 條第 2 款規定參照），或經自治條例明確授權之地方行政機關訂定之自治規則，為居民自由權利之限制依據。
- 3、是以，對於自治事項，地方自治團體本得制定自治條例以為限制居民基本權利之法規範依據，無需中央法規之授權。縱認為仍應有中央法規之授權，則依司法院釋字第 38 號及第 738 號解釋之意旨，憲法第 118 條及憲法增修條文第 9 條等規定已明確揭示直轄市之自治，以及省、縣地方制度，委由立法

者以法律定之之授權意旨。立法者依此授權所制定之地方制度法第 25 條與第 28 條第 2 款分別規定：「直轄市、縣(市)、鄉(鎮、市)得就其自治事項或依法律及上級法規之授權，制定自治法規。」、「下列事項以自治條例定之：……二、創設、剝奪或限制地方自治團體居民之權利義務者。」基此，地方自治團體倘就其自治事項或依法律及上級法規之授權，於合理範圍內以自治條例限制居民之基本權利，與憲法第 23 條所規定之法律保留原則亦無牴觸。

- 4、依題所示，既然行政法院已認定甲直轄市以系爭規定強制外送平台業者以自己費用，為其外送員投保強制汽車責任保險，係屬甲直轄市勞工安全衛生之地方自治事項，則依前所述，甲直轄市本得制定自治條例以為限制居民基本權利之法規範依據，無待中央法規之授權。故行政法院認為系爭規定違反法律保留原則之見解，並無理由。縱認為甲直轄市仍須有中央法規之授權，方能就自治事項制定自治條例以為限制居民基本權利之法規範依據，前述地方制度法第 25 條與第 28 條第 2 款等規定，性質即屬中央法規之授權規定；且基於憲法對地方自治之制度性保障，該等概括授權亦已符合法律保留原則之授權要求。換言之，甲直轄市依據地方制度法該等概括授權規定而就自治事項制定自治條例，以限制居民基本權利，並無違反法律保留原則之要求。

第(三)子題

本子題涉及地方自治團體之自治條例遭中央監督機關函告無效後，地方自治團體有無可能，以及應為如何之法律救濟問題。

- 1、依憲法訴訟法第 83 條第 1 項第 1 款規定，地方自治團體之自治條例經監督機關函告無效者，就依法定程序用盡審級救濟而受之不利確定終局裁判，認為損害其受憲法所保障之地方自治權者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。
- 2、中央監督機關就地方自治團體之自治條例所為之函告無效，性質係屬中央監督機關依地方制度法第 30 條第 4 項規定，針對地方自治團體此一特定對象，就其立法機關所議決通過之自治條例有無牴觸憲法、法律或基於法律授權等上位階法規範此一具體事件，所為對外直接發生使牴觸上位階法規範之自治條例為無效之法律效果的單方行政決定，應屬行政處分。受函告無效之地方自治團體如不服中央監督機關所為該等函告無效之行政處分，應以之為程序

標的，依訴願法第 1 條第 2 項規定與行政訴訟法第 4 條規定，循序提起訴願與撤銷訴訟等法律救濟途徑以為救濟。

- 3、至於應以何者為適格之訴願人及原告而循序提起訴願與撤銷訴訟部分，或有以司法院釋字第 527 號解釋意旨為依據，認為受函告無效者，既為地方自治團體之立法機關所議決通過之自治條例，就此所生侵害地方自治團體自治立法權限之公法上爭議，地方立法機關自得代表地方自治團體而以當事人身分，提起訴願與撤銷訴訟。或有認為直轄市政府、縣市政府等地方行政機關，得以該函告無效之利害關係人身分，提起訴願與撤銷訴訟。或有認為該等地方行政機關作為函告無效之相對人，本得代表地方自治團體而以當事人身分，提起訴願與撤銷訴訟；至於地方立法機關則是作為函告無效之利害關係人，而以訴願或訴訟參加之方式成為當事人。
- 4、如依晚近行政法院較為一致之裁判見解，由上級監督機關就自治條例所為之函告無效，性質係屬限制地方自治團體自治立法權之負擔處分，其所歸屬之權利主體為地方自治團體。對之如有不服，原則上應以自治權限受侵害之「地方自治團體」公法人本身為訴願人及原告，循序提起訴願與撤銷訴訟，始屬當事人適格。於此，依訴願法第 20 條第 2 項、地方制度法第 55 條第 1 項與第 56 條第 1 項等規定，並應以直轄市市長、縣（市）長等地方行政首長為代表人，代地方自治團體為訴願及訴訟行為。
- 5、依上所述，就行政院函告系爭規定無效此一行政處分部分，如有不服，應以甲直轄市為原告，其市長為代表人，循序提起訴願及撤銷訴訟以為法律救濟。對於此部分答題之關鍵點，在於應考人能否瞭解所謂原告適格之問題，所指為何，以及能否掌握行政法院近期較為一致之裁判實務見解，或由學理觀點分析應以何者為訴願人及原告而循序提起訴願及撤銷訴訟以為救濟。
- 6、甲直轄市循序提起訴願及撤銷訴訟用盡審級救濟後，如受不利確定終局裁判，而認為損害其受憲法所保障之地方自治權者，得以該不利之確定終局裁判為憲法訴訟之程序標的，依憲法訴訟法第 83 條第 1 項第 1 款規定聲請憲法法庭就該裁判為宣告違憲之判決。
- 7、至於在適格之聲請人方面，由於目前尚無相關案件得以探知憲法法庭之實務見解，故此部分容有不同見解表述之可能。例如應考人或可由該條款規定之規範文義為答題之依據，主張其已清楚揭示係以地方自治團體為規範對象，

且既然係以地方自治團體所受之不利確定終局裁判損害其受憲法保障之地方自治權為聲請之事由，則亦應以地方自治團體為聲請人，並依地方制度法第 55 條第 1 項與第 56 條第 1 項等規定，以地方行政首長為代表人。從而得出應以甲直轄市為聲請人，以甲直轄市市長為代表人提出聲請之結論。

【閱卷委員的話】

本題係結合時事議題，以地方自治團體就自治事項行使立法權限所制定之自治條例為爭點之開展，結合行政法總論、地方制度法、訴願法與行政訴訟法，以及憲法訴訟法相關問題，目的在於測驗應考人對於與地方自治有關之行政法基本與進階概念之掌握程度，以及前述各該法領域相關規定之理解與運用能力。嚴格而言，本題之三項子題所涉之爭點可謂十分單純；且經由各該子題之設計，亦已相當明確地揭示應考人所應予回答之爭點。也因此，應考人如能瞭解並確實掌握各該子題之爭點，輔以相關法律規定及學理與實務見解，而依一般法學論理邏輯順序為答題，均可獲致一定之分數。茲就應考人各該子題之答題情形，分述如下：

第(一)子題

- 1、如前所述，本子題涉及行政法院是否享有審查地方自治團體所制定之自治條例，並進而於個案中拒絕適用之權限，以及其得否依憲法訴訟法向憲法法庭聲請法規範憲法審查此二項爭點。
- 2、於第一項爭點部分，多數應考人除提及憲法第 80 條規定外，亦多能援引司法院釋字第 137 號與第 216 號等解釋，作為其論述行政法院於審理案件時，對於法規命令與行政規則等行政命令，得審查其合法性與合憲性，並進而以其違法或違憲為由，而予以拒絕適用之依據。少數應考人則是能進而提及司法院釋字第 590 號解釋所揭示，對於形式意義之法律，包括行政法院在內之各級法院不得以經認定其為違憲為由而逕行拒絕適用，僅能聲請憲法法庭為法規範憲法審查之解釋意旨，以作為其就本子題為答題時之論理大前提。就此，均值得肯定。
- 3、然而，本子題此一爭點之答題關鍵，在於應考人應釐清地方自治團體所制定之自治條例於整體規範位階秩序中之定位為何。就此，應考人之答題情形可謂五花八門。少部分之應考人係以地方制度法第 30 條第 1 項規定為依據，

論述性質屬地方自治團體自治條例之系爭規定，在整體規範位階秩序中，地位係居於中央法規命令之下。換言之，其既然非屬形式意義之法律，位階又較中央法規命令為低，則行政法院於審理案件時，當不受其拘束，而得對之進行合法性與合憲性審查；並於認定其違憲時，得予以拒絕適用。此等論述內容，一般可獲致相當不錯之分數。少部分之應考人則是一方面肯認系爭規定非屬形式意義之法律，但另一方面則是基於其係經地方立法機關議決通過而具有一定程度之民主正當性之觀點，認為行政法院仍應受其拘束；就此，基於學理亦有類似見解之主張者，故而亦視其論理之完整性而給予相應之分數。

- 4、然而，有更多的應考人是在幾乎未有任何論理或說明之情況下，即直接得出行政法院於審理案件時應受，或不受系爭規定拘束之結論。更有以系爭規定係屬自治條例之規定，既有「條例」二字，則依中央法規標準法第 2 條規定與第 4 條規定，系爭規定性質即屬形式意義之法律。此等答題內容即無法獲致高分。
- 5、於行政法院得否以系爭規定違憲為由，而依憲法訴訟法向憲法法庭聲請法規範憲法審查之爭點部分，多數應考人均能援引憲法訴訟法第 55 條規定為答題之依據。然而，對於憲法訴訟法該條規定所定之法律位階法規範此一聲請要件，卻有極為不同之理解與詮釋。應考人如能掌握憲法訴訟法第 54 條規定之修正說明所示「……未達法律位階之法規範（例如行政命令或行政函釋等），各法院於審判案件時，本得依法表示適當之見解，不受該法規範拘束（司法院釋字第一三七號解釋參照）……」，以及第 55 條規定之修正說明所示「行政命令是否違憲，各法院應自為審查表示其合法適當之見解（司法院釋字第一三七號解釋參照），爰排除在各法院得聲請憲法法庭判決之列」等內容，應可知悉憲法訴訟法第 55 條規定所定之法律位階法規範，係指前述形式意義之法律，或學理所稱之國會法。縱使不知該等修正說明之內容，亦應可由憲法訴訟法相關規定已明確將作為聲請標的之法規範，區分為法律位階與命令位階二類（例如憲法訴訟法第 52 條規定）之規範內容，推知該二類法規範各有不同之概念內涵才是。
- 6、少數以地方制度法第 30 條第 1 項規定為答題依據之應考人，於此亦多能前後一致地認為系爭規定既非形式意義之法律，當然亦非屬憲法訴訟法第 55

條規定所定之法律位階法規範，故行政法院對之，即不得依憲法訴訟法該條規定，向憲法法庭聲請法規範憲法審查；除此之外，並有極少數之應考人能輔以司法院大法官第 1513 次會議議決關於「自治條例並非屬法官得聲請解釋之客體」之見解為答題。此等邏輯前後一致或引經據典之答題內容，均能獲得相當之分數。然而，為數甚多之應考人若非根本不知憲法訴訟法有將法規範區分為法律位階與命令位階二類，以及法官僅能就法律位階法規範向憲法法庭聲請法規範憲法審查，即係在未經充分，甚至未有任何說理之情況下，逕自將系爭規定定性為法律位階法規範，並進而得出行政法院對之得向憲法法庭聲請法規範憲法審查之結論。凡此也就難以獲致高分。

第(二)子題

- 1、本子題之核心爭點，在於地方自治團體就自治事項制定自治條例而涉及對居民基本權利之限制時，是否仍須有中央法規之特別授權，方與法律保留原則無違而屬適法。就此，如前述評分要點所示，有認為既然係地方自治團體針對自治事項行使立法權限，則依司法院釋字第 806 號解釋，本即得在無中央法規特別授權之情況下，以自治條例為限制居民基本權利之規範依據。但亦有認為，於此等情形仍有法律保留原則之適用，只是基於憲法對於地方自治之制度性保障所生應對地方自治團體自治權限予以尊重之觀點，僅需憲法與中央法規之概括授權即可，而無需中央法規之特別授權。此等論理方式或可見於司法院釋字第 38 號解釋所稱「……至縣議會行使縣立法之職權時，若無憲法或其他法律之根據，不得限制人民之自由權利」，以及釋字第 738 號解釋所稱「又自治法規除不得違反中央與地方權限劃分外，若涉人民基本權利之限制，仍應符合憲法第二十三條之法律保留原則。就此，憲法第一百十八條就直轄市之自治，委由立法者以法律定之；嗣憲法增修條文第九條亦明定省、縣地方制度以法律定之。地方制度法乃以第二十五條規定：『直轄市、縣(市)、鄉(鎮、市)得就其自治事項或依法律及上級法規之授權，制定自治法規。』第二十八條第二款規定：『下列事項以自治條例定之：……二、創設、剝奪或限制地方自治團體居民之權利義務者。』基此，地方自治團體倘就其自治事項或依法律及上級法規之授權，於合理範圍內以自治條例限制居民之基本權利，與憲法第二十三條所規定之法律保留原則亦尚無牴觸」。少數之應考人能掌握前述核心爭點，並依前述說明而援引相關大法官解釋為答題之依據，因此而能獲致高分。

- 2、然而，即便本子題在題幹中已經明確地揭示，行政法院已認為強制外送平台業者以自己費用，為其外送員投保強制汽車責任保險屬於勞工安全衛生之地方自治事項之見解，絕大多數之應考人卻仍援引並解析憲法法庭 111 年憲判字第 6 號判決關於中央與地方權限劃分之論理內容，討論系爭規定強制外送平台業者以自己費用，為其外送員投保強制汽車責任保險是否屬於甲直轄市之自治事項，並據而論斷行政法院之見解有無理由。此等無法確切掌握本子題爭點之情形，縱使答題內容引經據典，仍屬未針對本子題爭點為答題之情形，僅能獲致一定之分數。因此，本子題得分高低差異極大。
- 3、少數應考人雖能領會本子題之前述爭點，但卻無法掌握相關大法官解釋與學理之見解，若不是認為系爭規定因欠缺中央法規之特別授權而違反法律保留原則，即係以牽強附會之方式，嘗試從本題所附之強制汽車責任保險法、保險法，以及職業安全衛生法等參考法條中，推導出其係屬特別授權予地方自治團體制定系爭規定之中央法律規定，並進而獲致系爭規定符合法律保留原則要求之結論。此外，部分應考人則是以本題所附之地方制度法第 18 條規定作為系爭規定之中央法規授權依據，然答題之內容卻置重於論述地方制度法該條規定不符合授權明確性原則之要求，並進而得出系爭規定違反法律保留之結論。然而，姑且不論其錯誤援引法律規定及錯置重點之情形，既然係地方制度法該條規定違反授權明確性原則之要求，理應係其違反法律保留原則才是，何以卻是得出系爭規定違反授權明確性之要求而與法律保留原則相牴觸之結論，論理邏輯紊亂之答題內容，也就難以作為給分之依據。

第(三)子題

- 1、本子題之核心爭點，在於測試應考人能否掌握憲法訴訟法關於地方自治團體聲請解釋憲法之最新法制規定。也因此，如能以憲法訴訟法第 83 條第 1 項第 1 款規定為起點開展本子題之答題內容，應屬於較為妥適之答題方式。
- 2、然而，在所附參考法條已含括憲法訴訟法之情況下，仍有為數眾多之應考人於答題時，若非係未以憲法訴訟法第 83 條第 1 項第 1 款規定為依據，即係以憲法訴訟法該條項第 2 款關於「地方自治團體其立法機關議決之自治事項，經監督機關函告無效」之規定，為答題依據。此等未明確揭示所依據之法條，或援引錯誤之法條為依據之答題情形，對分數造成一定之影響。
- 3、在憲法訴訟法第 83 條第 1 項第 1 款規定之脈絡下，地方自治團體應依法定

程序窮盡救濟途徑後，方能就所受之不利確定終局裁判，向憲法法庭聲請為宣告其無效之判決。因此，於此須先行探究地方自治團體應依何等法定程序窮盡救濟途徑；而此，則又取決於行政院就系爭規定所為之函告無效，係屬何等性質之行政行為而定。

- 4、對於該等函告無效，絕大多數應考人均能援引行政程序法第 92 條規定而將其定性為行政處分，並進而以之作為依訴願法第 1 條第 2 項規定進行訴願程序，與依行政訴訟法第 4 條規定提起撤銷訴訟之程序標的。其中，對於該等函告無效所得進行之法律救濟途徑，少數應考人並能於有限之答題時間內清楚說明司法院釋字第 527 號解釋及當時部分行政法院裁判見解，以及憲法訴訟法生效施行後在法律救濟途徑方面所生之差異。但有部分應考人似乎無法確切掌握行政行為與相應之行政訴訟類型間之關聯性，進而出現於此應進行課予義務訴訟，或是確認行政處分違法或無效之訴訟以為法律救濟之答題內容。更有甚者，將行政訴訟法所定之各種訴訟類型逐一列出，或是認為應就系爭規定提起確認違法訴訟。此等答題內容，當然也就無法獲致相當的分數。
- 5、至於在原告適格方面，答題內容則呈現較為歧異之情形。部分應考人似乎無法區分地方自治團體與地方自治團體之機關二者之不同，從而不時出現甲直轄市之丙市政府或乙議會為地方自治團體公法人之答題內容。更有甚者，或係因無法瞭解本子題題幹所揭示之爭點，而出現討論外送平台業者能否於何等情況下，得針對行政院之函告無效提起訴願與撤銷訴訟之答題內容。
- 6、部分應考人援引司法院釋字第 527 號解釋意旨，認為於此因涉及地方自治團體立法權限之限制，故而應以甲直轄市乙議會為適格之原告，就該函告無效提起訴願及撤銷訴訟。但亦有援引學理見解，而由縱使函告無效所涉及者，為地方自治團體之自治立法權限，其仍係屬於該地方自治團體自治權限此等性質屬團體權限之一環，故而應以甲直轄市為適格之原告提起訴願及撤銷訴訟，並以甲直轄市之市長為代表人。此外，亦有援引晚近行政法院較為一致之見解為答題依據者，而認為原則上應以甲直轄市為適格之原告提起訴願及撤銷訴訟，並以甲直轄市之市長為代表人；但如由該等函告無效係否定地方立法機關之立法決議，直接侵害其本於地方制度法所取得之法定權限之觀點而論，則以其立法機關為原告，提起訴願與撤銷訴訟，亦具原告適格。此部分係依應考人論理之完整性，以及其能否掌握行政法院前述近期較為一致之

裁判實務見解，或能否由學理觀點分析應以何者為訴願人及原告而循序提起訴願及撤銷訴訟以為救濟，而給予相應之分數。

- 7、至於在憲法訴訟之問題方面，縱使憲法訴訟法第 83 條第 1 項第 1 款規定已經清楚揭示係以地方自治團體於依法定程序窮盡救濟途徑後所受之不利確定終局裁判為聲請標的，除有根本未提及憲法訴訟法該款規定之情形外，更有為數眾多之應考人或係因無法掌握憲法訴訟法該款規定所定之訴訟類型及其程序標的，因而出現以系爭規定，甚或是以地方制度法第 30 條第 4 項規定為程序標的，向憲法法庭聲請宣告其違憲之判決此等明顯錯誤之答題內容。
- 8、最後，在適格之聲請人方面，如前述評分要點所示，由於目前尚無相關案件得以探知憲法法庭之實務見解，故此部分容有不同見解表述之可能；例如或可由憲法訴訟法該款規定之規範文義出發，或是由地方自治團體之團體權限觀點切入，抑或是援引過往相關司法院大法官解釋為據。換言之，於此端視應考人之答題情形而給予相應之分數。